

1500373-14.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... apreendida lhes pertencia e era destinada ao tráfico.

Os policiais militares apresentaram relatos coesos, indicando como procederam a abordagem e a forma com que encontraram as drogas. Afirmaram ainda que, ao indagarem o réu e o menor, ambos confirmaram que praticavam o tráfico de drogas no local.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500373-14.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500373-14.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2074580/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 16820154 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 1289/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2074580 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2074580/2021 - DEL.SEC.TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO MARCONDES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

ALEXSANDRO MARCONDES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos às fls. 41, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, na forma do artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, c.c artigo 29 do Código Penal, sob a acusação de que, na tarde de 16 de março de 2021, por volta das 14h00m, na Rua Projetada E, nas imediações de estabelecimento de ensino ali localizado, no Bairro Água Quente, nesta cidade e comarca, agindo em concurso - tanto na ideação como na execução - com o menor inimputável, adolescente infrator, Igor da Silva Portela, trazia consigo, para o fito de entregar a consumo de terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, sessenta e um gramas e noventa e oito centigramas (61,98 g), aproximadamente, da droga Cannabis Sativa L (maconha) e oito gramas e trinta centigramas (8,30 g) do entorpecente cocaína, determinantes de dependência física e psíquica, consoante testifica o auto de constatação acostado nos autos e conforme o demonstrará laudo de exame químico toxicológico que oportunamente se entranhará.

Consta na denúncia que, encontrava-se a maconha distribuída em sessenta e três (63) invólucros e a cocaína parte em cinco (5) unidades contendo a substância ilícita em sua forma compacta (pedras de crack) e parte em onze (11) envoltórios contendo esta droga em sua forma pura e natural (pó branco de granulometria fina), repartidos os narcóticos em embalagens preparadas como porções individuais para a venda no varejo.

É da inicial que as drogas destinavam-se à mercancia ilícita, conforme se depreende de sua quantidade, forma de apresentação e diversidade, assim como do horário e local de sua apreensão, esta ocorrida por ocasião de patrulhamento policial de rotina efetuado no local, oportunidade em que o réu e o adolescente que o acompanhava foram surpreendidos quando, hirtos e estáticos na via pública, sentados sobre a calçada, possivelmente aguardavam contato com usuários para vender-lhes as substâncias ilícitas, constatando-se, então, que o réu tinha consigo, no bolso da bermuda que trajava, um invólucro contendo maconha e um microtubo de cocaína e o menor, também no bolso de sua bermuda, uma embalagem contendo maconha, tendo ambos ocultado o restante das drogas, guardadas em um estojo de óculos e numa garrafa plástica, junto ao muro de uma escola existente no local, no interior de um buraco nesta estrutura.

A prisão em flagrante do réu foi homologada e lhe foi deferida a liberdade provisória (fls. 63/69 e 91/92).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 79/80), o réu foi pessoalmente notificado (fls. 99) e apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (fls. 93/95).

A denúncia foi recebida em 13 de setembro 2021 (fls. 100/101) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 127).

Em instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, salientando as declarações testemunhais e a prova pericial, além do fato de que foi o réu quem indicou onde estava a droga. Pena majorada, regime mais gravoso.

Já a Defesa requereu a desclassificação para o crime do artigo 28, salientando que a prova é incerta com relação ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento, pois o réu não vendeu drogas na creche, apenas guardava drogas ali. Igualmente não foi comprovada a corrupção do menor, que já era conhecido de abordagens anteriores. Por fim, entendeu cabível o privilégio, com a fixação do regime aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/42), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelo laudo do exame de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 27/35), pelas fotografias dos itens apreendidos (fls. 36/38), pela fotografia do réu (fls. 39), pela fotografia do menor (fls. 40), pelo documento de identidade do menor infrator (fls. 42), pelo exame químico-toxicológico, que constatou a presença das substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC) nos materiais apreendidos (fls. 129/132) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O réu, ouvido em solo policial (fls. 08/09), declarou que “dispensa a assistência de advogado para este ato, porém, por não possuir recursos para custear sua defesa, solicita que lhe seja concedido um defensor público; afirma que seus familiares estão cientes de sua prisão, os quais foram cientificados através da genitora do interrogado; afirma não possuir passagens criminais pretéritas; afirma ser usuário de maconha há aproximadamente dois anos; afirma ser solteiro e não ter filhos; afirma ser garçom, porém se encontra desempregado há aproximadamente um mês; quanto aos fatos ora apurados afirma que, conhece e mantém amizade com o adolescente Igor

da Silva Portela; afirma que nesta data de 16/03/2021, como de costume, se dirigiu à rua e se sentou na calçada onde passou a utilizar seu telefone celular; afirma que não possuía nenhum entorpecente em sua posse; afirma que momentos mais tarde, o adolescente Igor da Silva Portela chegou onde o interrogado se encontrava e, conversando brevemente convidou o interrogado para fumarem juntos um cigarro de maconha e comprarem pasteis para comer, o que o interrogado concordou, não sabendo informar se o adolescente já possuía maconha consigo ou se ainda iria comprar; afirma o interrogado que mal concordou em fumar o cigarro de maconha, foram abordados pelos policiais militares e, revistado, nada de ilícito foi encontrado em seu poder; afirma o interrogado que lhes foi determinado pelos policiais militares que permanecessem sentados na calçada e, por tal razão não presenciou os policiais darem buscas no local, tão pouco encontrarem drogas; afirma o interrogado que nenhuma droga apreendida nestes autos lhe pertence e, que em momento algum assumiu a responsabilidade por tais drogas" (sic).

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu disse que tem 19 anos. Nunca foi preso, nem abordado pela polícia. Trabalha de garçom no espetinho. Era usuário de droga. Usava cocaína e maconha. Faz dez meses que parou de usar drogas. Conhece Igor do futebol, treinavam juntos. O local em que foram abordados é perto da casa de sua mãe e na rua da casa dele. Mora com sua namorada. Foram fumar maconha e comer pastel. Pegou uma bucha de maconha e um pino de cocaína. Igor pegou uma bucha de maconha. Os meninos correram. Foram em direção ao local que vendia pastel. Os policiais acharam a droga. Falaram que não estavam vendendo. Os policiais procuraram e acharam droga no muro da creche. Perguntaram se era deles, falaram que não, que eram somente usuários. Foram levados para a delegacia. Sua mãe estava junto com ele na delegacia e ficou com vergonha de falar na frente dela que trazia drogas consigo, porque ela não sabia que ele era usuário de drogas. Ela acompanhou seu depoimento. A viatura ficou na frente deles. Não mostraram as drogas quando acharam. Não viram eles achando as drogas. Quando chegou na delegacia soube que a droga foi encontrada ali. Viu a pessoa que vendia a droga pegando no muro da creche. Pagou 15 no pino e 5 na maconha. Não estavam usando ainda quando foram abordados.

A testemunha Igor, ouvida na delegacia (fls. 20), informou que "trabalha como chapeiro há 4 anos com o irmão Emerson da Silva e que não tem filhos; indagado sobre os fatos, disse que estava com seu amigo Alexsandro e que iriam comprar pastel. Enquanto estavam aguardando, disse que iriam fumar maconha; menciona que a Polícia Militar chegou para efetuar a abordagem e que, enquanto um policial os vigiava, outro foi até o 'mato' perto do local e voltou com mais entorpecentes. Questionado se estes entorpecentes eram de sua posse, respondeu que não e que só estava fumando maconha" (sic).

Em juízo a testemunha Igor disse que chamou o réu para comer pastel e fumar maconha. Comprou a maconha, ele comprou um pino de cocaína. Compraram pastel. Foram abordados. Mostraram o que tinham, um pino de cocaína e a maconha. Tinha os meninos que venderam a droga, mas correram. Os policiais foram procurando as coisas, atrás do muro, acharam e falaram que era tudo deles. Tinha uma bucha de maconha e o réu tinha uma bucha de maconha e um pino de cocaína. A droga estava na escola, atrás do muro. Não sabe que escola era. O réu trabalhava, fazendo espetinho, trabalhava de garçom. Nunca ouviu falar que ele vendesse drogas. Tinha sete ou mais pessoas ali. Não correram porque não deviam nada. Nunca respondeu a processo na vara da infância. Usava maconha. O réu parou de usar há um ano e pouco. Antes ele usava maconha e cocaína. Pagou 5, ele pagou na média de 20 reais.

As testemunhas André e Caetano, policiais militares, ouvidas na delegacia (fls. 17 e 18/19), relataram que "procediam patrulhamento pelo Bairro Água Quente, nesta cidade quando ao acessarem a Rua Projetada E lograram avistar as pessoas posteriormente identificadas como sendo o maior Alexsandro Marcondes de Oliveira e o menor Igor da Silva Portela, os quais se encontravam sentados na calçada e, ao avistarem a viatura policial, imediatamente se levantaram tentando deixar o local, conduta que despertou suspeita motivando a imediata abordagem de ambos que, em seguida foram revistados, sendo encontrado na posse do maior Alexsandro Marcondes

de Oliveira, mais precisamente no bolso da bermuda que trajava, um invólucro contendo maconha e, um microtubo (eppendorf) contendo em seu interior cocaína e, com o menor Igor da Silva Portela, lograram localizar no bolso da bermuda que trajava, um invólucro contendo maconha e, questionados quanto ao entorpecente, confessaram estarem naquele local com o propósito de venderem entorpecente e, questionados se possuíam mais drogas, responderam que possuíam, indicando o muro da escola atravessando o muro onde, num buraco da parede haviam um estojo de óculos e, uma garrafa plástica, contendo em ambos entorpecentes que, contabilizados no total de 61 (sessenta e um) invólucros de maconha, 5 (cinco) invólucros de crack e, 10 (dez) eppendorfs de cocaína, razão pela qual foi dada a voz de prisão" (sic).

Em juízo o policial Caetano disse que ao adentrar a via viram os dois sentados na esquina. Eles tentaram levantar para se evadir. Com o réu tinha um pino de cocaína e um invólucro de maconha. Com o menor um invólucro de maconha. Eles confessaram o tráfico e indicaram o local em que a droga estava. Não havia mais ninguém por ali. Depois fizeram a varredura, mas não acharam mais nada. Acharam a droga no local indicado por eles. Não se lembra da quantidade, era maconha e cocaína, dividida em porções, iguais as que estavam com eles. Estavam em um estojo de drogas e numa garrafa pequena plástica localizada depois, na varredura. Acredita que devido a pandemia não estava havendo aula na escola. Não conhecia o réu. Aquela rua é conhecida pela venda de drogas, não um local só. Não sabe quem é o responsável pela venda ali. A garrafa estava no buraco também. Eles não estavam comendo pastel quando foram abordados.

Em juízo o policial André Luiz disse que ao ver a viatura eles tentaram fugir. O menor tinha uma bucha de maconha, com o maior uma porção de maconha e uma de cocaína. Eles admitiram que faziam o tráfico e disseram que a droga estava no muro de uma creche municipal. Estava dentro de um estojo, repartida em porções, cocaína e maconha. No buraco havia também uma garrafinha de água. Somente os dois estavam naquele local. Acredita que apenas escondiam ali, não viu ninguém, não havia criança no local. Não os viu fazendo a venda. Eles apenas levantaram e tentaram sair. Conhecia somente o menor, de outras abordagens. Não disseram há quanto tempo estavam ali. Só falaram que era para levantar dinheiro. Os dois falaram que estavam vendendo, não só o menor.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando encontraram o réu e o menor infrator, sentados na calçada, próximos de uma escola municipal/creche, e, ao perceberem a presença da guarnição, adotaram comportamento suspeito, levantando-se imediatamente assim que viram a viatura, ensejando a abordagem.

Submetidos à revista pessoal, os militares encontraram, em posse do réu, um microtubo de cocaína e uma porção individual de maconha. Em revista ao menor, localizaram uma porção de maconha.

Inquiridos informalmente pelos agentes, os réus assumiram que estavam praticando o tráfico de drogas no local, indicando, ainda, que tinham ocultado drogas no muro de uma escola, em frente ao local da abordagem.

Os agentes realizaram vistoria no local indicado, e encontraram, no buraco que havia na estrutura do muro da escola, sessenta e um invólucros de maconha, cinco pedras de crack e dez microtubos contendo cocaína, todos acondicionados em uma garrafa plástica e em um estojo de óculos.

A Autoridade Policial, o réu negou o tráfico de drogas e disse que desconhecia os entorpecentes apreendidos pelos policiais militares. Alegou que em momento algum assumiu a responsabilidade das drogas aos policiais e que, embora fosse usuário, não trazia nenhuma droga consigo.

Em juízo, também disse que não traficava, mas admitiu que trazia consigo uma porção de cocaína e outra de maconha. Disse que mentiu na delegacia porque sua mãe não sabia que era usuário e foi ouvido em sua presença. Mas na delegacia o réu negou que trouxesse drogas consigo, mas afirmou ser usuário.

O que se percebe é que o réu não quis dizer na delegacia que trazia porções de droga consigo porque estava vendendo drogas no local e talvez sua mãe desconheça a mercancia ilícita. Preferiu negar todos os fatos.

Em juízo, negou apenas a venda, no que foi acompanhado pelo menor Igor.

Igor, todavia, é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, pois os policiais informaram que já foi várias vezes abordado no local, conhecido pela mercancia ilícita.

Além disso, foram o réu e o menor que indicaram aos policiais onde estava escondida a droga, em local difícil de ser localizado. O réu admitiu que sabia onde a droga estava, embora tenha negado que fosse sua.

Os policiais, todavia, afirmaram com firmeza, na delegacia e em juízo, que o réu e o menor admitiram estar fazendo a venda no local e que toda a droga apreendida lhes pertencia e era destinada ao tráfico.

Os policiais militares apresentaram relatos coesos, indicando como procederam a abordagem e a forma com que encontraram as drogas. Afirmaram ainda que, ao indagarem o réu e o menor, ambos confirmaram que praticavam o tráfico de drogas no local.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de agentes de segurança pública.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do agente público, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir em agentes públicos ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Sobre a questão, como já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP - Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Ora, os agentes públicos não tinham por que incriminar o réu, que sequer conheciam. Portanto, a autoria delitiva é irrefutável.

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo, e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que o réu trazia consigo e guardava as drogas apreendidas, portanto, desnecessário ter sido o réu flagrado em ato de venda.

Nesse sentido: "Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação" (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câ. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

Ainda que fosse usuário, o que não se dúvida, a circunstância não descaracteriza o crime.

“O traficante pode também ser viciado e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo para uso próprio e para a disseminação do vício; por outro lado, o viciado também pode ser instrumento de difusão do mal, quando fornece a droga a outrem. Em ambas as hipóteses acima referidas, prevalecerá o delito mais grave, ficando absorvido o delito do artigo agora comentado. Tanto no caso de um traficante que traz consigo a droga para uso próprio como no caso de alguém que, trazendo originalmente para uso próprio, vem a desviar essa destinação fornecendo-a a outrem, o bem jurídico atingido é a saúde pública em sua forma substancialmente mais grave, não podendo o que dissemina o vício beneficiar-se arguindo sua condição de usuário da droga” (“Tóxicos Prevenção Repressão”, Vicente Grecco Filho, Saraiva, 7ª edição p.119).

As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

O laudo do exame químico-toxicológico comprovou a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína encontradas nos materiais apreendidos (fls. 129/132).

Sobreleva notar que a quantidade de drogas apreendidas (61,98g de maconha, 7,5g de cocaína em sua forma pura – pó branco de granulometria fina e 0,8g de cocaína em sua forma petrificada – crack), a forma de acondicionamento (a maconha distribuída em 63 invólucros, o crack fracionado em 05 pedras e a cocaína distribuída em 11 microtubos), as circunstâncias em que ocorreram a apreensão (policiais que realizavam patrulhamento de rotina próximo ao local, quando encontraram o réu, na companhia de um menor infrator, próximos a uma escola, com comportamento suspeito, ensejando a abordagem pessoal), evidenciam de forma clara o intuito da mercancia. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, mostra-se presente, haja vista que a infração, inequivocamente, foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino.

Ora, é de se observar que a referida causa de aumento é objetiva, pouco importando se restou comprovado nos autos ou não que o ilícito visava atingir pessoas que eventualmente estariam na escola.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06. AFASTAMENTO. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE INCIDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA.

ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, ou mesmo de o comércio visava a atingir os estudantes, as pessoas hospitalizadas, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotráfica. Na espécie, o paciente foi flagrado praticando condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 nas imediações dos estabelecimentos Unidade de Saúde da Família - Dr. Luís Spina e do CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), restando plenamente justificada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas (...)” (STJ, HC n. 359.088/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/10/2016 – destaquei).

Também está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois, conforme demonstrado nos autos, o adolescente infrator Igor foi igualmente flagrado levando consigo entorpecentes. Ressalto que o comércio era realizado na presença e com a participação do menor infrator, demonstrando o seu irrefutável envolvimento.

Como se sabe, a capacidade de resistência das crianças e adolescentes, em virtude de seu amadurecimento incompleto, é menor, razão pela qual podem ser envolvidos por traficantes, não somente para consumir drogas como também para distribuí-las.

Sabe-se que o termo “envolver” traz o menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto, e que o termo “visar” é ter o menor como meta para o uso das drogas. Sua menoridade está evidenciada, pois, na época dos fatos, tinha 17 anos de idade, conforme demonstra seu documento juntado às fls. 42.

No presente caso, evidente, portanto, que o réu envolveu o menor na empreitada criminosa, devendo ter considerado em sua pena a causa de aumento insculpida no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Para a configuração da causa de aumento não é necessário que o réu corrompa o menor, mas apenas que pratique o crime com ele.

É de se observar, ainda, que o réu não possui antecedentes desabonadores, levando a crer que o réu não se dedica a atividades criminosas. Desta forma, preenchidos os requisitos legais, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, com fundamento no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06. Deve o acusado, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 33, caput e §4º, c.c. o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n.º 11.343/2006, verifico que o réu não ostenta antecedentes desabonadores (fls. 43 e 122/123). Deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a variedade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, considerando a natureza deletéria de uma das drogas apreendida, cocaína em forma de pedra crack, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas extremamente violentas nos casos de abstinência e que acaba empurrando os usuários a outros crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais e mais drogas, bem como considerando a variedade de droga apreendida (maconha, cocaína e crack) o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, indicando que o réu está lidando com diversos tipos de drogas e alcançando um número maior de usuários, evidenciando sua maior dedicação em comerciar entorpecentes, em detrimento da saúde de terceiros, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, ficando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A exasperação da pena base mostra-se necessária em razão da natureza da droga traficada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça deste país.

Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 2. Trata-se o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de norma de direito material de observância obrigatória quando da fixação da pena nos delitos por ela regulados por imperativo constitucional, eis que beneficia o agente dada a possibilidade de redução da reprimenda. 3. Faz jus à diminuição da pena o paciente que preenche todos os seus requisitos, não sendo motivação idônea para se afastar a incidência da minorante a menção no sentido de ser o paciente detentor de maus antecedentes levando-se em conta condenação ainda não transitada em julgado. 4. Habeas corpus denegado, e concedida a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena do paciente na ação penal de que aqui se cuida a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa” (STJ, HC 152.285/SP, Ministro Relator Haroldo Rodrigues, j. em 23/02/2010 - destaquei).

O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“A reprimenda mostrou-se adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 126 tráfico) e pela potencialidade lesiva da droga, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 125 roubo

circunstanciado), alcançando a pena final de 07 anos de reclusão; não aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante da reincidência. Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como estabelecida" (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0004327-68.2012.8.26.0292. Relator Des. Marco de Lorenzi. J. em 04/07/2013 - destaquei).

Ausentes agravantes e, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena imposta ao réu em 1/6, retornando a pena ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo impossível a redução da pena nesta fase aquém deste patamar mínimo.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desposado na Súmula n. 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Presente as causas de aumento, previstas no artigo 40, inciso III e VI, da Lei n.º 11.343/2006, elevo a pena do réu em 1/5, para que fique em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pois o crime foi cometido nos arredores de instituição de ensino e envolvendo adolescente.

Em razão do que preceitua o § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, por ser o réu é primário, de bons antecedentes, inexistindo notícia de que integre organização criminosa ou prova de que vinha traficando há tempos, reduzo a reprimenda em 2/3, o que resulta em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. À míngua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Considerando a decisão proferida no HC n.º 596.603, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 08 de setembro de 2020, bem como à vista dos elementos dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (pena não superior a quatro anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais que não são desfavoráveis) do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem o réu direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal. Inviável a suspensão condicional da pena, porquanto a pena restritiva de direitos é ao réu mais benéfica.

Em caso de revogação do benefício, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR ALEXSANDRO MARCONDES DE OLIVEIRA, filho de Dair José de Oliveira e Raquel Marcondes Gomes do Prado, RG n.º 62.612.100, nascido aos 19 de agosto de 2002, natural de Pindamonhangaba/SP, como incurso no artigo 33, caput e §4º, c.c. o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal. Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º,

§9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, a depender dos documentos a serem apresentados pela Defesa, se concedidos os benefícios da Justiça gratuita (decisão de fls. 128).
Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.
P.R.I.C. Oportunamente ao arquivo.
Taubaté, 28 de janeiro de 2022.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA